

1501260-32.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... onde confessou que realizava o tráfico de drogas, que vendia cada pedra de crack por R\$10,00 e que o dinheiro encontrado em seu poder era oriundo do tráfico. A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2020 (fls. 66/69).

O réu foi citado (102) e apresentou Defesa (fls. 99/101).

Em instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Mauro Alexandre Estevam dos Santos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501260-32.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501260-32.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcus Gabriel Leite Rosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

MARCUS GABRIEL LEITE ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 11h, na Avenida Vila Rica, nº 274, Estiva, nesta cidade e comarca de Taubaté/SP, adquiriu e trazia consigo para fins de tráfico, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu adquiriu as drogas em data pretérita e ignorada, levando-as consigo até ao local dos fatos para fazer a venda a terceiros. Acionados através de denúncia anônima, Guardas Municipais realizaram patrulhamento no local para averiguar a prática do delito, cuja denúncia apontava um indivíduo de cor parda, magro e altura mediana, que fazia o tráfico ilícito de entorpecentes na Avenida Vila Rica. Ao adentrarem na citada avenida, visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, que ao notar a aproximação dos agentes públicos, demonstrou nervosismo e aparentou esconder algo nas mãos, o que levou os guardas a abordá-lo.

Identificado como Marcus, em revista pessoal, em seu poder foi localizado, na mão direita, uma pedra de crack pesando 0,18g. Em suas vestes íntimas, no interior de

sua cueca, foram localizadas mais 07 pedras de crack, pesando 1,17g, estando as drogas embaladas separadamente e prontas para a venda. Foi localizado, ainda, em poder do acusado, um aparelho celular e a quantia de R\$40,00 em notas trocadas. O réu foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia, onde confessou que realizava o tráfico de drogas, que vendia cada pedra de crack por R\$10,00 e que o dinheiro encontrado em seu poder era oriundo do tráfico.

A denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2020 (fls. 66/69).

O réu foi citado (102) e apresentou Defesa (fls. 99/101).

Em instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Mauro Alexandre Estevam dos Santos e Caian de Moraes Rodrigues, sendo o réu interrogado (fls. 136/137).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requereu a aplicação da pena-base acima do mínimo legal pela natureza das drogas apreendidas (crack), a aplicabilidade do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas em percentual máximo (2/3), fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, com possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, além do perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

De outro lado, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, vez que sua prisão e o processo decorreram de provas inválidas, originadas da atuação de guardas civis que não ostentam permissão legal para a atuação fiscalizatória ostensiva. Destacou que o réu negou os fatos, foi orientado a confessar para que fosse liberado, sendo que não foi flagrado em atos de mercancia ilícita. Aduziu que meros indícios não são suficientes para embasar a condenação do acusado; que o dinheiro encontrado em seu poder tinha origem lícita, do trabalho com seu avô. Neste contexto, pleiteou a aplicação do Princípio in dubio pro reo, devendo ser reconhecida a improcedência da ação penal. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento do privilégio do art. 33, §4º da Lei de Drogas em seu grau máximo e fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18), pela fotografia (fls. 19), Laudo de Constatação Provisória (fls. 21/25), pelo comprovante de depósito (fls. 52), Exame Químico-Toxicológico (fls. 96/98), bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, vejamos:

A testemunha Mauro Alexandre Estevam dos Santos, Guarda Municipal, disse que recebeu uma denúncia anônima com as características de um indivíduo, que estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes próximo ao coreto. Foram até o local averiguar e se depararam com um indivíduo com as mesmas características, e o abordaram. O réu tinha uma pedra de crack nas mãos e outras sete em suas vestes. Havia uma quantia em dinheiro em seu poder, mas não se recorda quanto. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Tem bastante denúncias naquele local (o coreto). Não se recorda se o acusado confessou o tráfico. Não conhecia o réu. As drogas estavam separadas e individualizadas. A denúncia anônima decorreu, nesse caso, de uma pessoa que passou pela viatura e apresentou as informações. Após receber a denúncia, passa para seu superior a ocorrência e ele autoriza ou não a averiguação do caso. O réu estava sentado, quando ele viu a viatura, se abaixou e escondeu alguma coisa nas mãos, mas não conseguiu ver o que era; o abordou. As características do acusado também batiam com a descrita pela denunciante. Pelo que se lembra, a denúncia descrevia uma pessoa morena e de estatura mediana. Não se recorda das roupas do réu. Não o viu vendendo drogas, mas ele estava com droga na mão. Não sabe se o réu estava sob efeito de entorpecentes.

A testemunha Caian de Moraes Rodrigues, Guarda Municipal, disse que abordaram o réu no coreto da Estiva. A diligência se deu através de uma denúncia anônima, passadas as características do indivíduo. De posse das informações, foram em patrulhamento ao local e localizaram o indivíduo indicado. Feita a abordagem, com ele foram encontradas uma pedra de crack em sua mão, sete pedras de crack na cueca, R\$40,00

em dinheiro e um celular. A denúncia mencionava que a pessoa estava realizando o tráfico no local. O réu confirmou que estava realizando o tráfico e disse que quando terminava sempre passava uma pessoa para fazer a recolha. O réu informou que vendia cada pedra por R\$10,00. O local é conhecido pela venda de drogas. Não conhecia o réu. Não se recorda direito, mas acha que a denúncia anônima chegou ao seu conhecimento através no número 153. As denúncias funcionam como se fosse o COPOM da Polícia Militar. A ocorrência é repassada pela central de comunicação (CECOM). A comunicação é repassada para o superior do dia, e ele pede que se faça o patrulhamento no local. Abordou o acusado devido as suas características e porque, ao chegar no local, ele demonstrou certo nervosismo tentando esconder algo nas mãos. Não viu o réu vendendo entorpecentes. O réu estava sóbrio, não aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

O réu Marcus Gabriel Leite Rosa, em solo policial (fls. 05), confessou que estava vendendo as pedras de crack para sobreviver e que cobrava R\$10,00 por cada pedra; o dinheiro encontrado em seu poder era proveniente da venda de drogas; não foi agredido nem ameaçado pelos guardas civis.

Em juízo, o acusado disse que é usuário de drogas e não traficante. Não estava no coreto para vender drogas. Comprou aquelas drogas para usar durante a semana. Trabalha numa serralheria com seu avô. Falaram para o depoente confessar, que assim o liberariam para ir embora. Comprou as pedras de crack com um conhecido. Estava usando as pedras no coreto; mora perto do coreto. Os R\$40,00 encontrados em seu poder eram decorrentes de seu serviço. Não conhecia os policiais que realizaram sua abordagem. Quando foi preso estava sob efeito de drogas.

Reproduzida a prova oral e comprovada a materialidade delitiva, resta a análise quanto à sua autoria, o que também se demonstrou incontestado nos autos.

Os depoimentos dos guardas civis foram harmônicos no sentido de que, após uma denúncia anônima que descrevia um indivíduo que estava praticando o tráfico de drogas na região do coreto da Estiva, se dirigiram para o local, e encontraram o réu Marcus, que apresentava as mesmas características que lhes foi repassada, oportunidade em que o acusado, visualizando a chegada dos agentes públicos, demonstrou bastante nervosismo e tentou esconder algo nas mãos.

Diante da conduta suspeita, decidiram abordá-lo e, em revista pessoal, encontraram em suas mãos uma pedra de crack e em suas vestes, na cueca, outras sete pedras da mesma droga, todas separadas e prontas para a venda.

Indagado, extrajudicialmente o réu confessou a prática da mercancia ilícita, afirmando que o fazia para sobreviver, vendendo os entorpecentes por R\$10,00 cada pedra.

Descreveram os guardas municipais que em poder do acusado ainda foi apreendida a quantia de R\$40,00, que ele confessou ser produto do tráfico de drogas e um celular.

Diante deste contexto, a negativa do acusado em juízo restou isolada no acervo probatório.

Por seu turno, não vislumbro qualquer ilicitude na conduta dos guardas municipais que, recebendo notícia da ocorrência de grave crime que estaria sendo cometido, ao averiguar os fatos, constatarem a veracidade da denúncia, surpreendendo o réu na posse de entorpecentes de alto poder viciante e prontos para a venda, sendo o réu detido em flagrante delito.

Note-se que a prisão em flagrante delito é legalmente permitida para qualquer um do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

É exatamente este o entendimento dos tribunais superiores e especificamente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme já se decidiu:

Desacato. Delito devidamente caracterizado. Dolo verificado. Atuação dos guardas civis dentro da legalidade. Fato típico. Pena bem dosada. Negado provimento ao recurso (TJ-SP - APR: 15007394220218260072 SP 1500739-42.2021.8.26.0072, Relator: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Data de Julgamento: 29/09/2021, Turma Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06)- Apelo do

Ministério Público postulando a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, reputando-se lícita a atuação dos guardas civis municipais - Possibilidade - Prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais - Provas obtidas por meios lícitos - Nulidade inexistente - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais - Responsabilização inevitável - Apelo provido (TJ-SP - APR: 15012487020208260536 SP 1501248-70.2020.8.26.0536, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 23/08/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Guardas Civis. Tratando-se de prisão em situação ostensiva de flagrante de crime importante, nada há de ser reparado na atuação de guardas civis, cujo depoimento, aliás, não cabe ser repellido tão somente em vista da condição funcional das testemunhas, senão, se o caso, por sua desarmonia com o quadro de convicção que os autos autorizam (TJ-SP - APR: 00018251220178260542 SP 0001825-12.2017.8.26.0542, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019).

Outro ponto de destaque é a validade do depoimento dos guardas civis, que se equiparam aos policiais militares quando agem como testemunhas, sendo pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "o depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013), não havendo razão bastante para se duvidar da palavra dos milicianos, principalmente, porque seus depoimentos se encontram de acordo com as demais provas produzidas, sendo que eles, conforme relatado, sequer conheciam o réu antes aos fatos.

A potencialidade lesiva das drogas restou evidenciada pelo Laudo de Constatação Provisória (fls. 21/25) e pelo Exame Químico-Toxicológico (fls. 96/98), sendo irrelevante a discussão acerca da efetiva circulação das drogas, visto que a tradição dos entorpecentes não é considerada requisito para a consumação do delito. Nesse sentido:

"Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação" (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antônio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

No entanto, não demonstrou a Defesa que o acusado se encontrava sob o efeito de entorpecentes no momento da abordagem.

Outrossim, nem mesmo eventual condição de dependente ou usuário tem o condão de descaracterizar o delito em tela, pois, é sabido, uma conduta não exclui a outra, podem ser praticadas pela mesma pessoa, e, além do mais, é comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do vício.

Pelos nortes traçados pelo art. 28 da Lei Antitóxicos, principalmente a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida, conclui-se que era utilizada para fins do art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, sem indícios que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, possível a aplicação de causa de diminuição prevista no art. 33, §4, da Lei 11.343/2006.

Deve ser reconhecida a confissão extrajudicial do acusado como circunstância atenuante, visto que foi levada em consideração para a formação da convicção do juízo, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação à não realização de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo órgão ministerial na presente lide, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é incabível o oferecimento de ANPP pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena mínima é superior a 4 anos, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do

Código de Processo Penal.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. AUSÊNCIA REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REAVALIAÇÃO. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP. 2. É inviável a análise acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado e da quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado sobre a condenação final. 3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 5. A revisão de ofício da necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) cabe tão somente ao órgão prolator da decisão, ou seja, ao juiz ou tribunal que decretou a custódia preventiva. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 145.629/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Dosimetria da pena.

Estabelecida a responsabilidade penal do acusado, passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, em observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei 11.343/2006, noto que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 30 e 71), contudo, teve apreendido em seu poder oito pedras de crack, droga de alto poder viciante que severamente atua dilacerando o tecido social, razão pela qual, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e no pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea ocorrida na fase inquisitiva (art. 65, III, “d” do Código Penal), vez que utilizada para o reconhecimento do crime e para a condenação do acusado, nos termos da Súmula 545 do STJ, razão pela qual, reduzo a reprimenda anteriormente fixada em 1/6, reconduzindo-a a seu patamar mínimo.

Na terceira fase, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, sem indícios que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, possível a aplicação de causa de diminuição prevista no art. 33, §4, da Lei 11.343/2006 e, por isso, reduzo a pena em 2/3, estabelecendo a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e no pagamento de 166 dias-multa, pena que torno definitiva, vez que inexistem outras causas modificadoras a serem consideradas.

Estabeleço o valor unitário da multa aplicada em 1/30 do salário mínimo nacional vigente, ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar majoração.

Em observância às Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, frente ao montante de pena aplicada e a sua primariedade.

Ante exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida para o fim de condenar MARCUS GABRIEL LEITE ROSA como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e no pagamento de 166 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, vez que ausentes motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, bem como pelo fato de sua condenação definitiva ter se dado em meio aberto.

Em observância aos requisitos enumerados no artigo 44 do Código Penal, reputo que o acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva

de direitos.
Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Precedente. 2. Ordem parcialmente concedida (STF - HC: 107071 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-048 DIVULG 07-03-2012 PUBLIC 08-03-2012).

Assim, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo nacional vigente, dirigidos à entidade a ser escolhida pelo juízo das execuções, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho do sentenciado.

Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Com fulcro no art. 63, I da Lei 11.343/06, determino o perdimento do dinheiro apreendido em poder do acusado, vez que não comprovada sua origem lícita.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Taubaté, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA